

0000187-92.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000187-92.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000187-92.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - EW7846-1/2022 - 3º Distrito Policial de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO LUIZ DOS SANTOS GATTI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

SERGIO LUIZ DOS SANTOS GATTI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, artigo 155, "caput", e no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos combinados com o artigo 71, todos do Código Penal, porque, no local descrito na denúncia, subtraiu, para si, no dia 11 de agosto de 2022, 04 pacotes de carne bovina (picanha), avaliados, no total, em R\$400,00, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado SUPERMERCADO PAGUE MENOS. Consta, ainda, tentou subtrair, no dia 12 de agosto de 2022, 07 pacotes de carne bovina (picanha) e 02 garrafas de vodka, marca Absolut, avaliados, no total, em R\$900,00, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado SUPERMERCADO PAGUE MENOS, não se consumando o

crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls. 91/93).

O réu foi citado (fls. 116), apresentando defesa prévia (fls. 127/128).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 138/139).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 144/150), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto.

O Doutor Defensor do réu requereu a absolvição ante o princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante, além da fixação de regime mais brando (fls. 153/161).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01, 13/14 e 21/23, e link de fls. 82.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse dos bens subtraídos. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, “De la Apreciación de las Pruebas”, tradução de

Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A testemunha Felipe, ouvida em Juízo, disse que trabalha na parte do açougue, e quando da apreensão do réu foi chamado para constatar os produtos. Informou que após confirmaram pelas câmeras de segurança a ação do réu. Por fim, sempre fazem controle dos produtos, e notaram que alguns haviam desaparecido, razão pela qual intensificaram a segurança.

A testemunha Rosciley, declarou que trabalha na função de segurança do estabelecimento comercial, sendo que no dia dos fatos, verificou, pelas câmeras, que o réu pegou um carrinho e colocou dentro dele uma mochila. No interior do estabelecimento pegou peças de carne, e garrafas de bebida, colocou no carrinho, e em outro corredor as colocou dentro da mochila. Disse, ainda, que reconheceu o réu, pelas imagens de câmera de segurança, como a pessoa que havia subtraído pedaços de carne no dia anterior, de forma semelhante. Narrou que o réu saiu da loja, sem passar pelo caixa, conseguindo aborda-lo e acionar a polícia.

Não há nos autos prova de que as testemunhas conhecessem o réu anteriormente ou que tivessem intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter os réus.

O policial militar esclareceu que receberam a informação acerca de um furto em andamento, onde o segurança do supermercado havia detido o indivíduo, no estacionamento. Dirigiram-se ao local, onde constataram que na mochila do réu existiam peças de picanha e duas garrafas de bebida alcoólica.

O réu, ouvido em Juízo, confirmou a prática dos furtos. Declarou que no dia anterior realmente subtraiu as quatro peças de picanha. Narrou que no outro dia retornou e subtraiu mais quatro peças de picanha e garrafas de bebidas, e ao sair do caixa foi abordado pelos seguranças. Informou que as carnes levou para casa para consumo e as bebidas iria vender os bens para comprar drogas.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

“É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem” (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado.

Com efeito, a prova nos autos demonstra que o réu subtraiu as peças de carne na primeira empreitada, e no dia seguinte, utilizando-se de semelhante execução, tentou subtrair novos bens, acabando por ser impedido por terceiros, restando caracterizado o furto, além da continuidade delitiva.

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a pretérita condenação do réu pela prática de crimes contra o patrimônio o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.

(...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade: 14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

PROVA - Maus antecedentes - Valor: 30(d) - Os antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto condenatório mas constituem importante adinículo para a formação do convencimento. (Apelação nº 1.171.909/6, Julgado em 03/02/2.000, 7ª Câmara, Relator: Corrêa de Moraes, RJTACRIM 47/133)

Não há que se falar em crime de bagatela ou insignificância, figura desconhecida no nosso ordenamento jurídico. O pequeno valor da coisa não serve para legitimar o comportamento em questão, mas apenas para eventual abrandamento de pena em caso de furto privilegiado, o que não ocorreu no presente caso.

Há que se analisar, ainda, que no presente caso, não se pode falar em pequeno valor do objeto subtraído. Ou irrelevância da ação, tendo em vista que não ocorreu a devolução do bem.

DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, IV) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO. CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE OS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – EXCLUDENTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO – CONDUTA QUE NÃO SE AFIGUROU IRRELEVANTE OU SEM REPERCUSSÃO PENAL – DOSAGEM DAS PENAS COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL FECHADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DOS RÉUS, MOSTRANDO-SE INVIÁVEL O DEFERIMENTO DE BENESSES – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0109069-21.2017.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples tentado - Materialidade e autoria comprovadas - Alegação do princípio da insignificância - Aplicabilidade - O princípio da bagatela não foi formulado para garantir indiscriminada impunidade daqueles que insistem em atentar contra o patrimônio alheio. Daí, o Pleno do Pretório Excelso, na relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, em análise conjunta dos HCs nºs. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, definiu que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso. O Tribunal da Cidadania, na esteira do entendimento da Suprema Corte, já preconizou a necessidade da concomitância de quatro pressupostos para o reconhecimento do crime de bagatela: “De acordo com a orientação traçada

pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (AgRg no HC 663.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser cabível o acolhimento de tal princípio quando o valor da res é inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...). (Apelação Criminal nº 1502811-44.2020.8.26.0619, Taquaritinga, rel. Adilson Paukoski Simoni, j. 02/06/2022)

Na doutrina de Júlio Fabrini Mirabete:

"A excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, não está inserida na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 3/345) .

(...) Segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial. (Manual de Direito Penal, 21a. Ed. vol. I, p. 118/119)

E o próprio Mirabete exemplifica:

"É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja o efetivo desfalque do patrimônio alheio". (Idem, vol.II, pág.225/226).

O Desembargador Souza Nery, de forma assaz pertinente, assim coloca a questão:

"Quanto à tese do crime de bagatela, entendo que não se aplica ao caso o chamado princípio da insignificância. O ordenamento jurídico brasileiro não contemplou – malgrado o desejo de muitos – o princípio da bagatela, a cujo respeito já se disse decorrer de verdadeira insignificância de princípios." (TJSP – AC - 990.09.058638-9, 9ª Câmara Criminal, j. 27.08.09).

Da mesma forma, o Desembargador Xavier de Aquino entende que a pequena quantia subtraída ou o pequeno valor da coisa furtada não tornam atípica a conduta, embora possam, desde que presentes outros requisitos, permitir o reconhecimento do furto privilegiado. De acordo com o eminente Magistrado:

"Pensar de forma diferente seria transformar as ruas em palco de treinamento para delinquentes. Se apanhados permanecem impunes diante da aplicação do princípio da insignificância. Por outro lado, se a conduta é bem sucedida também saem ilesos". (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 990.09.218713-9, Americana, 11ª Câmara Criminal, j. 09.12.2009).

Em julgado da apelação nº 0001914-88.2012.8.26.0581, da Comarca de São Manoel-SP, assim decidiram nossos tribunais.

"Tocante à aplicação do princípio da insignificância, deve-se ter em mente que o fato não pode ser considerado atípico somente em decorrência do valor da coisa furtada, ou porque os bens foram recuperados. Para tanto, creio ser indispensável a presença de outros requisitos estabelecidos pela doutrina e pela Jurisprudência: 1) ofensividade mínima; 2) ausência de periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade; 4) inexpressividade da lesão jurídica causada (STF, HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de

19/11/04; HC 96.202;/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/05/10; STJ, REsp 1133800, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/06/10; HC 164.993/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 14/06/10; HC 152.738/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJe de 15/03/10).

O réu é reincidente (certidões de fls. 11/12 do autuado em apenso), ostentando condenações pela prática de tráfico de drogas e furto. A nova investida contra o patrimônio alheio, portanto, denota que sua conduta é dotada de ofensividade e reprovabilidade, na medida em que deixa entrever a presença de destemor, de uma quase certeza da impunidade, fazendo emergir a expressividade da lesão, a encomendar a intervenção do Direito Penal. Nesse sentido: STF "O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal", HC 102.088, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/05/10.

Não se pode confundir baixo grau de lesividade com sua absoluta inexistência, pena de adotar-se, como regra, a impunidade em casos como os em comento. Daí porque se justifica a "persecutio criminis in juditio".

Nos dias atuais, em que a sociedade presencia o recrudescimento de toda espécie de criminalidade, em que as instituições responsáveis pela aplicação da lei e pela manutenção da segurança e ordem pública sofrem com o descrédito da população, em que a sensação de insegurança está pulverizada em todo o corpo social, o princípio da insignificância deve ser aplicado com redobrada cautela, devendo constituir exceção e não regra, pois do contrário o Judiciário estará alimentando esse sentimento de desassossego, fomentando o crime e a impunidade.

Pelo que tenho notado a jurisprudência não se pacificou com relação à incidência do princípio. Pelo contrário, atualmente tem passado a analisar o crime sob o enfoque da vítima, sob o prisma de quem está perdendo — e para quem, via de regra, a conduta é dotada de lesividade. Nesse sentido pronunciou-se o Min. Luiz Fux no julgamento do HC nº 100.690 (Supremo Tribunal Federal): "Eu tenho muita preocupação com essa teoria, porque as jurisprudências dos tribunais têm um caráter exemplificativo para a sociedade. Então, se nós chegamos aqui para dizer que furtar dois DVD's não é crime, nós estamos exatamente tornando antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita". (AC 2014.0000633914, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Orlando, 06.10.2014).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

PENAL - FURTO - PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - APREENSÃO DA RES PALAVRAS DE TESTEMUNHAS RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO LEGAL - PENA E REGIME REESTRUTURADOS - PENA CORPORAL SUBSTITUÍDO-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Não cabe ao Poder Judiciário a aplicação do princípio da insignificância, porquanto constitui função do Poder Legislativo selecionar os critérios da tutela penal dos bens jurídicos. - Estando comprovada a autoria do delito pela confissão do agente, apreensão da res furtiva em seu poder e depoimento de testemunhas, a condenação é medida que se impõe. Sendo a apelante primária e a res furtiva de pequeno valor é de se reconhecer o furto privilegiado na espécie nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação nº 990.09.366733-9 - 12ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi - j. 19.05.2010)

FURTO - Bem subtraído que possui valor econômico, ainda que pequeno - Reconhecimento de crime de bagatela - Impossibilidade: 52(a) - Quando o bem subtraído possui valor econômico, ainda que pequeno, é impossível o reconhecimento do crime de bagatela, não se caracterizando o delito do art. 155 do CP apenas quando não se puder avaliar o produto do furto diante da insignificância da lesão jurídica, como na subtração de um ovo, de ramas de mandioca, de folhas de palmeira

etc. (Apelação nº 1.101.025/3, Julgado em 14/09/1.998, 12ª Câmara, Relator: José Habice, RJTACRIM 41/170).

No mais, a existência da prática reiterada de crimes, comprovado nos presentes autos com a reincidência e/ou maus antecedentes, impossibilita a análise do referido benefício.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusado que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 557.194/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. BEM DE VALOR CONSIDERÁVEL. ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A conduta narrada nos autos se amolda tanto à tipicidade formal e subjetiva, quanto à tipicidade material, que consiste na relevância jurídico-penal da ação, pois o valor do bem subtraído não se revela ínfimo, correspondendo a cerca de 37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo certo que o furto em questão não representa fato isolado na vida do paciente, que já foi condenado por crime semelhante, impondo-se, portanto, a incidência da norma penal de modo a coibir a reiteração criminosa. 3. (...). (HC n. 330.156/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 10/11/2015.)

Verifica-se, também, que não há que falar-se em inimputabilidade em razão de consumo de substância entorpecente e/ou álcool. Primeiro, porque não comprovada. Segundo, porque a ingestão de bebida alcoólica, ou droga, só é excludente de culpabilidade se oriunda de fato culposo ou de força maior. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

DANO QUALIFICADO, DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE CIRCUNSTANCIADA, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE, COM REDUÇÃO DAS PENAS. Materialidade e autoria dos delitos bem demonstradas nos autos (...). SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. Não há que se falar em inimputabilidade ou em semi-imputabilidade da apelante, pois tanto o artigo 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal, como os artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, exigem, para a isenção ou redução da pena, que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e a dependência ou o efeito de droga, sejam provenientes de caso fortuito ou força maior, e que o agente, em razão da embriaguez, dependência ou efeito de drogas, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já a embriaguez, voluntária ou culposa, como no presente caso, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, inciso II). Adoção legislativa da actio libera in causa, de modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de ebriedade. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500190-16.2019.8.26.0585; Relator (a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de exame de dependência químico-toxicológica. Inocorrência. Ato justificadamente indeferido pelo magistrado no exercício de seu livre convencimento motivado - Mérito Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Condenação mantida. Pleito de isenção de pena, com encaminhamento a tratamento adequado à dependência química, nos termos do art. 45, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Dispositivo legal que exige comprovação da inimputabilidade ou prática do delito sob efeito de drogas em razão de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos, não bastando a mera alegação de dependência química. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0001976-42.2009.8.26.0288; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 03/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima e confissão parcial dos acusados que, aliados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito - Inimputabilidade que não restou comprovada - Eventual atuação delitiva sob efeito ou dependência de droga que não decorreu de caso fortuito ou força maior - Condenação mantida - (...). (TJSP; Apelação Criminal 0053723-90.2014.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

Relativo a primeira subtração, a consumação ocorreu em razão do bem ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando a recuperação posterior. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Em relação à segunda tentativa, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual seja, teve sua ação foi interrompida por terceiros.

Por fim, no presente caso, os dois delitos de mesma espécie ocorreram em um pequeno lapso de tempo, e deve ser considerada a continuidade delitiva, com o acréscimo previsto no artigo 71 do Código Penal. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

Apelação criminal. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Apelo Defensivo buscando absolvição, por falta de provas, ou a fixação de regime prisional menos gravoso - Materialidade e autoria comprovadas réu que foi reconhecido por ambas as vítimas réu e comparsa que cometerem o primeiro roubo, com simulação de uso de arma de fogo, subtraindo o celular do ofendido, e se evadiram. Na sequência, com mesmo 'modus operandi', réu e

comparsa abordaram a segunda vítima no veículo, no interior do qual havia duas crianças, e anunciaram o carro. Vítima que implorou para retirar as crianças, e o comparsa do réu se evadiu com tal veículo, ainda com uma das portas abertas, deixando o réu para trás. Populares que ouviram os gritos e lograram deter o réu até a chegada da Guarda Municipal. Delitos de roubo majorados perfeitamente delineados Continuidade delitiva mantida, diante das circunstâncias de tempo, praticados em locais próximos e com mesmo 'modus operandi' - Dosimetria Penas-base fixadas no mínimo legal, sem recurso Ministerial Sem alterações na segunda fase Na terceira fase, exasperação decorrente do concurso de agentes, e em razão da continuidade delitiva - Regime inicial fechado bem justificado Correção de erro material no dispositivo da sentença quanto à capitulação referente à continuidade delitiva (art. 71, do CP) - Recurso improvido. (Apelação nº 0004227-49.2015.8.26.0635, da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora: ELY AMIOKA, Data: 09/11/2017)

CRIME CONTINUADO - Dois delitos de roubo, um simples e consumado, e outro circunstanciado e tentado, praticados na mesma Cidade, no mesmo dia, com diferença de poucas horas - Reconhecimento - Possibilidade: 25 - É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo, um simples e consumado, e outro circunstanciado e tentado, praticados na mesma Cidade, no mesmo dia, com diferença de poucas horas. (Apelação nº 1.098.723/0, Julgado em 28/05/1.998, 16ª Câmara, Relator: Mesquita de Paula, RJTACRIM 39/99)

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 54/61) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para cada delito de furto.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é também multirreincidente, inclusive específico, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 54/61, a qual resta parcialmente compensada ante sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), razão pela qual a pena em acréscimo à pena base em 1/7 (um sétimo), perfazendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. (...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (Tema 585 - REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Justificada a valoração negativa da conduta social, em razão do cometimento do delito pelo Recorrente quando em gozo do livramento condicional. Precedentes. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias. 3. Tratando-se, no entanto, de réu que possui tripla reincidência, não é possível promover a compensação total entre a confissão e a reincidência, pois configura circunstância mais reprovável do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.751.712/R0, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

Tendo em vista que um dos delitos de furto se deu na forma tentada, diminuo a pena em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido, que se aproximou sobremaneira da consumação, porquanto chegou sair do estabelecimento com os objetos, perfazendo assim um total de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Por fim, ante a ocorrência de crime continuado (art. 71, do CP), e considerando a quantidade de comprovadas participações (duas), aumento a pena a pena mais grave, ou seja, a do furto consumado, de 1/6 (um sexto), e fixo a pena em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu não poderá apelar em liberdade, por ser reincidente. Além disso, o réu encontra-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu SERGIO LUIZ DOS SANTOS GATTI às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, "caput", e no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos combinados com o artigo 71, todos do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.
P. I. C.

Americana, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA